

1500219-48.2022.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... dos fatos estava sendo praticado o tráfico de drogas por indivíduo do sexo masculino, pardo, aparentemente jovem, com altura de 1,65m a 1,70m, usando bermuda e camiseta.

Assim, os policiais citados foram ao endereço apontado, onde avistaram o denunciado, pessoa conhecida pela prática do tráfico de drogas, mexendo no solo, em um pasto.

Em poder do denunciado, os agentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500219-48.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500219-48.2022.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Kauan de Andrade Sousa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. LUCAS KAUAN DE ANDRADE SOUSA, qualificado a fls. 16, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343, de 23.08.2006, porque

no dia 14 de abril de 2022, por volta das 5h50min, na Avenida 27 nº 1.725, Bairro Cohab I, nesta cidade e Comarca de Guaíra, teria em depósito, para finalidade de entrega ao consumo de terceiros, uma porção de maconha, com peso bruto aproximado de 1 g e também onze porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que “policiais militares receberam a informação de que no local dos fatos estava sendo praticado o tráfico de drogas por indivíduo do sexo masculino, pardo, aparentemente jovem, com altura de 1,65m a 1,70m, usando bermuda e camiseta.

Assim, os policiais citados foram ao endereço apontado, onde avistaram o denunciado, pessoa conhecida pela prática do tráfico de drogas, mexendo no solo, em um pasto.

Em poder do denunciado, os agentes encontraram a quantia de trinta e nove reais e cinquenta centavos, enquanto no local em que ele fora inicialmente visto mexendo, as drogas acima descritas.”.

Denúncia de fls. 64/65 recebida em 25 de abril de 2022 (fls. 67). Devidamente citado (fls. 81), o Acusado apresentou defesa preliminar (fls. 87/88), rejeitada por não configurar o caso de absolvição sumária (fls. 96/99). Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 134).

Em alegações finais o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela condenação do Réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 132/133).

A douta Defesa, por sua vez, ressaltou que o Réu deveria ser absolvido por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação do privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, com as consequências de praxe (fls. 135/137).

Eis o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/04), boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 10/11), na guia de depósito de fls. 76, no laudo de exame químico toxicológico (fls. 114/116) e pela prova oral colhida durante a persecução penal.

A autoria é certa contra o Réu que na fase inquisitorial confessou a prática do delito, ao declarar ser traficante de entorpecentes e que toda a droga localizada lhe pertence, assim como o dinheiro, fruto da traficância, ao passo que em Juízo alterou por completo aquele depoimento inicial, dizendo que apesar de traficar quando menor de idade, atualmente trabalhava e, por causa da pandemia, foi demitido, relatando que havia ido até o local dos fatos adquirir droga para o próprio consumo, recebendo ditas porções quando foi abordado pelos policiais no momento que faria uso, negando fosse traficante. Declarou, ainda, que na delegacia foi forçado a assinar o termo de declarações sem ler, porque sofreu tortura psicológica, foi ameaçado de agressão e aconselhado a confessar porque sairia da prisão, mas nada quis dizer sobre isso na audiência de custódia. Por fim, é usuário de drogas e era perseguido por policiais.

Sua versão final não se sustenta.

O policial militar Ednalvo Silva Santana Júnior disse, na fase judicial, que receberam denúncias de que um rapaz de bicicleta estaria traficando no local, para lá se dirigindo, encontrando o Réu agachado perto de um gramado, com a bicicleta ao

lado, guardando algo, realizando sua abordagem e encontrando o entorpecente, mais certa quantia em dinheiro. O Réu se limitou a dizer que havia “perdido”, não o conhecendo, por ser novo na cidade. Ademais, ele não aparentava estar sob efeito de drogas.

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policial, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo por que não pode ser descartado, notadamente porque o Réu não ofertou qualquer resistência válida ao seu depoimento, nem mesmo o contraditando.

A condição funcional não o torna suspeito, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram” (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10^a C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

A conduta do Acusado indica, pois, que no dia, horário e local apontados na denúncia, tinha em depósito substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente diversidade e quantidade de droga apreendida, em porções individuais prontas para comercialização, bem como a forma como estava o narcótico escondido em no solo, sendo avistado no momento em que ali mexia, além do fato de, na fase inquisitorial, ter confessado com detalhes a prática do crime.

Quanto a isso, aliás, o Réu foi ouvido em regular audiência de custódia, em momento algum reclamando sobre qualquer fato, sendo enfático ao negar agressão, tampouco que houvesse algum problema em sua oitiva na delegacia de polícia, muito embora tenha dito que ali informou que a droga era para seu uso. Ora, com a devida vênia, tivesse efetivamente sido coagido, teria prontamente relatado isso quando convidado a falar, absolutamente nada existindo a sugerir que fosse forjado na delegacia seu depoimento para, sabe-se lá por qual motivo, acusar indevidamente um inocente.

Tais condutas apontam que o Réu iria utilizar o entorpecente apreendido para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Importante destacar que o simples fato de ser usuário de drogas – sequer comprovado - não inibiria a conduta do narcotráfico, sendo que, muitas vezes, tais condutas caminham juntas, o que impede a desclassificação pretendida.

Dessa forma, considerando o quadro posto, descabe se falar em insuficiência probatória. Oportuno salientar que “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5^a C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Diante desse quadro probatório, não há como se deixar de reconhecer que no dia, horário e local indicados na denúncia o Acusado foi surpreendido quando tinha em depósito, para fins de comercialização, a substância entorpecente descrita na inicial.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo à dosimetria da pena.

Nesta fase inicial, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei de Drogas, é o caso de majorar a pena-base, tendo em vista que o Réu é portador de antecedentes, incluindo atos infracionais equiparados ao tráfico (cf. fls. 30/31 e 32/33), demonstrando que apesar de jovem persiste na prática de ilícitos, mormente constância na traficância, com claro indicativo da periculosidade do agente. Ressalto que se não é viável a majoração da pena por passagens pela Justiça menorista, é certo ser possível, nesta fase, a majoração diante da existência de atos infracionais como critério de majoração da pena diante da personalidade do agente, o que aqui se faz, porque, mesmo atingindo a maioridade penal há pouco tempo evidencia persistência na prática de condutas antissociais que não podem ser ignoradas, verbis: "A Terceira Seção desta Corte firmou orientação de que 'os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de 'crime' anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros" (RHC n. 63.855/MG, rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Dje 13/6/2016)'. " (STJ, RHC 96.158/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.08.2018). Sendo assim, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) e a fixo inicialmente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, à míngua de comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase, tem-se que o Acusado era menor de 21 anos à época da consumação do crime, retornando sua pena ao mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão. Importa destacar que não se pode falar em confissão porque o Réu, apesar do depoimento inicial, em Juízo prestou versão que não se mostrou verdadeira, visando, com isso, indevidamente se beneficiar com a desclassificação delitiva.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do narcotráfico, tendo em vista que ele, recentemente atingiu a maioridade penal e, antes disso, teve várias passagens por atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas, indicativo claro que não praticou o crime ao qual ora condenado de forma esporádica, agindo de forma repentina e incontrollável, mas um verdadeiro meio de trabalho ilícito.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'. Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico

apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.

Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Públ., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos subjetivo e objetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo

5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um “pequeno” traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito (sendo que o Réu não ostenta nenhum destes predicados) servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada que é ao crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: “Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto,

atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizada quantia em dinheiro vinculada ao crime, evidenciando-se ser o numerário fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido diploma legal, decreto a perda dos valores apreendidos com o Réu (cf. fls. 76), que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência CONDENO o Réu LUCAS KAUAN DE ANDRADE SOUSA, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu menor valor, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis. No mais, decreto o perdimento do valor apreendido com ele, este depositado em fls. 76 em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lancem seus nomes no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e encaminhe-se o dinheiro apreendido em fls. 76 em favor da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado e considerando a hediondez do tráfico de entorpecentes, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo por que mantenho sua prisão cautelar, sem prejuízo do conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nada justificando que depois de condenado a um crime equiparado ao hediondo, e tendo aguardado preso seu julgamento, fosse colocado em liberdade.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA